

1500931-43.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500931-43.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2160684/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18493223 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1633/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2160684 - 01º D.P. PIRACICABA, 1633/21/922 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

Vítima:

A COLETIVIDADE e outro

Artigo da Denúncia:

*

Aos 04 dias do mês de maio de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: João Erick da Silva Cerqueira e Márcio Andrade Felipe.

Observo que o réu entrou em contato com a assistente Hirlene, alegando que não havia recebido o link da audiência que já havia sido enviado para ele via e-mail em 29.03.2022(fls.120/122), sendo certo que foi novamente enviado o link via whats app, juntamente com o procedimento para ingresso na reunião do Teams. Porém, o réu só conseguiu ingressar na audiência às 15h30.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (João Erick e Márcio) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

“MM. Juíza, THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no incurso no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 porque, no dia 14 de junho de 2021, na rua Rangel Pestana, nº 1.039, bairro Centro, nesta cidade e comarca, portava o revólver, marca “Caramuru”, nº de série 6533, calibre 32, municiada com 06 cápsulas intactas, mantida em coldre, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

Autoria e materialidade foram devidamente comprovadas.

Segundo se apurou, guardas civis receberam informações de que “um indivíduo que estava na rua Rangel Pestana com a avenida Armando de Salles de Oliveira estava portando arma de fogo e que ele trajava roupa escura, moletom preto e tinha barba”. Assim, dirigiram-se ao local onde identificaram o denunciado com as vestimentas e características informadas.

Feita abordagem de praxe, na cintura do denunciado, os guardas apreenderam o revólver “Caramuru”, calibre 32, munido com 06 projéteis e no bolso uma pequena porção aparentava “cocaína”.

Instado, informalmente, o denunciado informou que “já fazia 30 dias que estava andando armado e gostava de portar a arma de fogo e não estava sendo ameaçado por ninguém e que a droga era para seu consumo pessoal”.

Perante a autoridade policial o denunciado alegou “ser o proprietário da arma e que é antiga e de relíquia”.

O laudo de exame pericial concluiu que a arma de fogo e as munições estavam aptas ao disparo (fls. 66/68).

Com efeito, a testemunha João Erick da Silva Cerqueira, guarda civil, disse “no dia de hoje, por volta das 17:11 horas, estavam em patrulhamento pela área central da cidade, quando foram informados via COP/CEMEL, dando conta que um indivíduo que estava na Rua Rangel Pestana com a Avenida Armando de Salles de Oliveira, o qual possivelmente estava portando uma arma de fogo, também sendo passado aos policiais as características deste indivíduo, que estava com roupa escura, trajando um moletom preto e com barba. Diante deste fato, os policiais foram até local informado, e quando chegaram visualizaram um indivíduo com as mesmas características da denúncia. Os policiais realizaram a abordagem policial, e em revista pessoal, foi localizado na sua cintura, dentro de um coldre, um revólver calibre 32, de marca Caramuru, carregado com 6 munições intactas, sendo ainda que esta arma está com a numeração aparentemente íntegra. Também foi localizado no bolso direito da calça do indivíduo uma pequena porção de substância aparentando ser COCAÍNA. Este indivíduo foi identificado por THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, que em entrevista informal com os policiais, alegou que já fazia mais de 30 dias que estava andando armado e que gostava de portar arma de fogo, e que não estava sendo ameaçado por ninguém, em relação a droga localizada em seu bolso alegou ser usuário e que a droga era para seu consumo pessoal. Alega o policial que houve a necessidade de usar algemas para evitar fugas” (fls. 04/05).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o guarda civil Marcio Andrade Felipe asseverou que “no dia de

hoje, por volta das 17:11 horas, estavam em patrulhamento pela área central da cidade, quando foram informados via COP/CEMEL, dando conta que um indivíduo que estava na Rua Rangel Pestana com a Avenida Armando de Salles de Oliveira, o qual possivelmente estava portando uma arma de fogo, também sendo passado aos policiais as características deste indivíduo, que estava com roupa escura, trajando um moletom preto e com barba. Diante deste fato, os policiais foram até local informado, e quando chegaram visualizaram um indivíduo com as mesmas características da denúncia. Os policiais realizaram a abordagem policial, e em revista pessoal, foi localizado na sua cintura, dentro de um coldre, um revólver calibre 32, de marca Caramuru, carregado com 6 munições intactas, sendo ainda que esta arma está com a numeração aparentemente integral. Também foi localizado no bolso direito da calça do indivíduo uma pequena porção de substância aparentando ser COCAÍNA. Este indivíduo foi identificado por THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, que em entrevista informal com os policiais, alegou que já fazia mais de 30 dias que estava andando armado e que gostava de portar arma de fogo, e que não estava sendo ameaçado por ninguém, em relação a droga localizada em seu bolso alegou ser usuário e que a droga era para seu consumo pessoal. Alega o policial que houve a necessidade de usar algemas para evitar fugas. Assim, diante do porte ilegal de arma de fogo o acusado foi encaminhado a este Plantão Policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária" (fls. 06).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. Disse que não conhecia o réu.

Perante a autoridade policial, o réu alegou "ser o proprietário da arma e que a mesma é arma antiga e de relíquia. Alega que tem o dinheiro para pagar a fiança e a recolhera. Em relação a droga alega ser usuário. Ademais manteve-se em silêncio" (fls. 07)

Em juízo, o réu que a arma foi apreendida na sua cintura. Não tem autorização para porte. Desconhece a droga apreendida. Falou que era sua na delegacia senão dissessem que não daria fiança. Não conhecia os guardas civis.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito imputado.

A narrativa dos guardas civis foi firme ao confirmarem que receberam informações de que o réu portava arma. Assim, feita abordagem em poder dele apreenderam o revólver "Caramuru", calibre 32, munido com 06 projéteis e no bolso uma pequena porção aparentava "cocaína". Informalmente ele alegou que gostava de portar a arma de fogo.

Assim, os elementos probatórios demonstram que o réu é o autor do delito. Em poder dele foi encontrada a arma de fogo, a qual foi considerada apta a efetuar disparos (fls. 64/65).

Outrossim, o réu não trouxe qualquer documento que comprovasse permissão para portar arma de fogo.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso Salienta-se que os policiais não tinham motivos para incriminá-lo injustamente. Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deverá ser fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes.

O réu é reincidente e a agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão, mesmo porque não foi determinante na prova, pois o réu foi preso em flagrante delito.

No entanto, caso seja considerada, deverá ser aplicada fração inferior à reincidência, que é preponderante.

Ausentes causas de aumento e diminuição.

O regime inicial deve ser o fechado diante da gravidade em concreto do delito e personalidade do réu (maus antecedentes e reincidente), necessário e proporcional à prevenção e reprovação do delito.

Incabível substituição da pena privativa por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Thiago dos Santos Rodrigues foi denunciado como incurso no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Segundo a denúncia (fls. 79-81), no dia 14 de junho de 2021, na rua Rangel Pestana, nº 1.039, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Thiago portava o revólver, marca "Caramuru", nº de série 6533, calibre 32, municiada com 06 cápsulas intactas, mantida em coldre, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, guardas civis receberam informações de que "um indivíduo que estava na rua Rangel Pestana com a avenida Armando de Salles de Oliveira estava portando arma de fogo e que ele trajava roupa escura, moletom preto e tinha barba". Assim, dirigiram-se ao local onde identificaram o réu com as vestimentas e características informadas. Feita abordagem de praxe, na cintura do réu, os guardas apreenderam o revólver "Caramuru", calibre 32, munido com 06 projéteis e no bolso uma pequena porção aparentava "cocaína". Instado, informalmente, o réu informou que "já fazia 30 dias que estava andando armado e gostava de portar a arma de fogo e não estava sendo ameaçado por ninguém e que a droga era para seu consumo pessoal".

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu: "alega ser o proprietário da arma, que é antiga, de relíquia. Tem o dinheiro para pagar a fiança e a recolhera. Em relação a droga, alega ser usuário" (fls. 7-8).

João Erick da Silva Cerqueira, guarda civil, relatou que: "no dia de hoje, por volta das 17:11 horas, estavam em patrulhamento pela área central da cidade, quando foram informados via COP/CEMEL, dando conta que um indivíduo que estava na rua Rangel Pestana com a avenida Armando de Salles de Oliveira, o qual possivelmente estava portando uma arma de fogo, também sendo passado as características deste indivíduo, que estava com roupa escura, trajando um moletom preto e com barba. Diante deste fato, foram até local informado, e quando chegaram visualizaram um indivíduo com as mesmas características da denúncia. Realizaram a abordagem e, em revista pessoal, foi localizado na sua cintura, dentro de um coldre, um revólver calibre 32, de marca Caramuru, carregado com 6 munições intactas, sendo ainda que esta arma está com a numeração aparentemente integral. Também foi localizado no bolso direito da calça do indivíduo uma pequena porção de substância aparentando ser cocaína. Este indivíduo foi identificado por Thiago dos Santos Rodrigues, e, em entrevista informal, alegou que já faziam mais de 30 dias que estava andando armado e que gostava de portar arma de fogo, e que não estava sendo ameaçado por ninguém, em relação a droga localizada em seu bolso alegou ser usuário e que a droga era para seu consumo pessoal. [...]" (fls. 4-5).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda civil Marcio Andrade Felipe (fls. 6).

Auto de exibição e apreensão juntado às fls. 14-15, fotografias, fls. 19-22 e laudo de exame, fls. 64-65.

Às fls. 108-110, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 3002538-54.2013.8.26.0451 - furto qualificado - trânsito em julgado para a Defesa em 24/10/2016, pena cumprida ou julgado extinta em 22/01/2019).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Com relação à materialidade e autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, ouvido João Erick da Silva Cerqueira, guarda civil. Relatou que estava em patrulhamento no centro e recebeu contato da central de monitoramento da GCM (CEMEL) indicando que um indivíduo com barba, descritas as vestes, estava portando uma arma de fogo. Foram ao local, abordaram Thiago, cujas características correspondiam às indicadas pela CEMEL, e, em revista pessoal, encontraram na cintura a arma indicada na inicial. Em seu bolso localizaram uma porção que parecia ser de cocaína. Thiago informou que usava a arma há um mês porque gostava, não tinha sido ameaçado, e que a droga era para uso pessoal. A olho nu, não era possível ver a arma embaixo das roupas de Thiago. A pessoa que operava a câmera disse que viu que Thiago estava possivelmente armado em um momento no qual ele movimentou a blusa.

b) Na sequência, ouvido o guarda civil Marcio Andrade Felipe. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda.

c) Interrogado, o réu Thiago dos Santos Rodrigues. Afirmou que a arma que foi encontrada em sua cintura era realmente sua. Pelo tempo que estava ali, não considera possível que o monitoramento da CEMEL o tivesse visto ali. Tinha acabado de chegar, estacionar a moto e comprar um suco e um salgado. Não foram nem 3 minutos. Acredita que estavam em busca de outra pessoa, mas por azar ele foi abordado e a pessoa procurada fugiu. Não tinha a documentação da arma e ela estava mesmo municiada com 6 cartuchos. Sobre a droga, desconhece. Na delegacia, disse que era sua e era usuário porque o delegado lhe disse que, se não assumisse, não fixaria fiança. Mas nunca usou cocaína. Não conhecia os guardas. Não foi abordado pelos guardas depoentes, mas sim um terceiro, que também não conhecia. Esse terceiro guarda abordou-o com arma em punho e já colocou a mão na sua cintura.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes, por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelos guardas municipais, não visualizaram a arma de fogo, mas sim receberam informação de terceiro que suspeitava da presença de arma com o réu. Sequer havia certeza. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as

guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido. Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019). Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão da arma, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de exame é provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao réu. Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, caso a prova não tenha sido considerada nula, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão, sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67. CP).

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

Tendo em vista que o réu é reincidente em delito diverso e a aplicação de pena restritiva de direitos se mostra socialmente adequada no caso concreto, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, §3º, CP).

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

Vistos.

THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso

nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 14 de junho de 2021, na Rua Rangel Pestana, nº 1.039, bairro Centro, nesta cidade e comarca, portava o revólver, marca "Caramuru", nº de série 6533, calibre 32, municiada com 06 cápsulas intactas, mantida em coldre, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, guardas civis receberam informações de que "um indivíduo que estava na Rua Rangel Pestana com a Avenida Armando de Salles de Oliveira estava portando arma de fogo e que ele trajava roupa escura, moletom preto e tinha barba". Assim, dirigiram-se ao local onde identificaram o réu com as vestimentas e características informadas.

Feita abordagem de praxe, na cintura do réu, os guardas apreenderam o revólver "Caramuru", calibre 32, munido com 06 projéteis e no bolso uma pequena porção aparentava "cocaína".

Instado, informalmente, o réu informou que "já fazia 30 dias que estava andando armado e gostava de portar a arma de fogo e não estava sendo ameaçado por ninguém e que a droga era para seu consumo pessoal". Perante a autoridade policial o réu alegou "ser o proprietário da arma e que é antiga e de relíquia".

O laudo de exame pericial concluiu que a arma de fogo e as munições estavam aptas ao disparo (fls. 66/68).

A denúncia foi recebida (fls. 84/85), o réu citado (fls. 92), apresentando resposta escrita, na qual alegou que as questões de mérito serão tratadas posteriormente (fls. 96/97).

O recebimento da denúncia foi mantido, designando-se audiência (fls. 98/100).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 02 testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que abordaram o réu depois de informação de que parecia estar na posse de armamento.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse do armamento, logo após a informação de que poderia estar armado, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal. Note-se que a Central de Monitoramento percebeu, quando a blusa do réu se levantou, que havia volume na sua cintura e, por isso, as testemunhas foram verificar e abordaram o réu.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º

603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - REsp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuarão sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime

inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

II - Do mérito

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, nas fotografias de fls. 19/22 e no laudo pericial de fls. 64/65, segundo o qual a arma de fogo estava apta para a realização de disparos e as munições eram eficazes.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu.

Na fase investigativa, o réu disse ser o proprietário da arma e que é antiga e uma relíquia. Em relação a droga, alegou ser usuário (fls. 07).

Em Juízo, o réu afirmou que a arma foi encontrada na sua cintura e era sua. Assim que chegou, estacionou a moto, comprou o salgado e o suco do ambulante, que estava no local. Não chegou nem a comer o salgado e beber o suco e já foi abordado. Não daria tempo de o monitoramento dizer que estava ali, porque foi muito rápido. Para ele, era outra pessoa que o monitoramento viu. Não tinha documento da arma. Ela estava municiada com 06 cartuchos. Desconhece a situação da droga, que falou que era sua, na Delegacia, porque disseram que se não o fizesse, não receberia a fiança. Foi outro guarda que o abordou, apontou a arma para ele e colocou a mão na sua cintura.

A confissão está amparada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O guarda municipal João Erick da Silva Cerqueira relatou que estava na área central, em serviço, quando a Central de Monitoramento Eletrônico avisou que visualizou no local um indivíduo com moletom preto, barba, o qual provavelmente estaria armado, fato que teria sido visto, quando ele levantou a blusa. Deslocaram-se ao local e se depararam com o réu, com as características indicadas. Abordaram o réu e, em busca pessoal, na cintura do réu, localizaram um revólver calibre 32, marca Caramuru, municiado. Em buscas, procuraram outros objetos que pudessem oferecer perigo e encontraram uma porção de cocaína. O réu falou que estava portando a arma de fogo há 30 dias, porque gostava e não estava sendo ameaçado. Quanto à droga, ele disse que era para seu consumo. Não conhecia o réu. Não conseguiu ver volume na cintura do réu.

No mesmo sentido, o depoimento do também guarda municipal Márcio Andrade Felipe que esclareceu que foram solicitados pela Central de Operações e pela Central de Monitoramento, no sentido de que havia um indivíduo nesse local, possivelmente armado, porque não conseguiam ver nitidamente, pelas imagens. Chegaram ao local e visualizaram o réu, com as características que tinham sido passadas. Em abordagem, encontraram com o réu, numa mão um soco de laranja e na outra um salgado. Levantou a blusa do réu e encontrou a arma na cinta. O réu falou que há 30 dias estava armado, que gostava de andar armado. Encontraram também uma porção de cocaína. Não conhecia o réu.

A prova é suficiente para a certeza da autoria.

Em solo policial, o réu confirmou ser o proprietário da arma, que é antiga e relíquia. Em audiência, o réu alegou que estava na posse da arma, quando houve a abordagem.

Os guardas municipais descreveram que a Cemel que informou que havia um indivíduo com certas características físicas e de vestimentas que estaria em determinado

local, possivelmente portando arma de fogo. Segundo os guardas, quando o réu levantou a blusa, viram alguma coisa, mas não tinham certeza. Eles foram ao local indicado e já avistaram o réu, com as características descritas. Ele foi abordado e, em revista pessoal, na cintura do réu, foi localizado o revólver calibre 32, da marca Caramuru, carregado com 06 munições intactas e com numeração íntegra. Além disso, no bolso do réu havia uma porção de cocaína. Indagado sobre a arma, o réu falou que estava andando armado há 30 dias, porque gostava, embora não tivesse sido ameaçado.

Nesse sentido, temos a mesma versão sobre os fatos, ou seja, o réu estava na posse da arma de fogo, quando foi abordado e os guardas civis encontraram o armamento. Sem controvérsia quanto à questão fática, a acusação tornou-se certa e a condenação se impõe.

Não há como negar, assim, diante desse conjunto probatório, que a arma de fogo apreendida estava na posse do réu e que ele não possuía documentação que possibilitasse tanto a guarda quanto o transporte do armamento, já que nenhum registro e porte foram juntados aos autos.

Nesses termos, diante da ausência de autorização para a portar a arma, o réu incorreu no crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A condenação, portanto, é de rigor.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal devem ser levadas em consideração.

O réu possui antecedentes criminais (certidão de fls. 109 – processo nº 3002538-54.2013.8.26.0451), devendo suportar pena-base acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A reincidência (certidão de fls. 109 – processo nº 1500391-63.2019.8.26.0599) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Nem se diga que a atenuante da confissão não pode ser compensada pela agravante da reincidência, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, dizem respeito ao réu e, portanto, são de mesma grandeza.

Sobre o assunto:

(...) 4. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

(...) 7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. "É firme o entendimento deste Superior

Tribunal de Justiça no sentido de que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no delito de furto, consoante disposto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 158, do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1838301/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Hipótese em que não foi realizado o exame pericial, nem tampouco foi apresentada justificativa para a sua inexistência, impondo-se o afastamento da qualificadora. Precedentes. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser

integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e concedeu a ordem de ofício para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e para determinar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. 6. Agravo desprovido. (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

(...) 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, uma vez que compreende a personalidade do agente, é circunstância deve ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 1608521/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tem, em tese repetitiva: "Confissão espontânea (atenuante) compensa a reincidência (agravante) na dosimetria" (Tema: 585).

Não há outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, em razão dos maus antecedentes e reincidência específica, a demonstrar que as penas anteriores não foram suficientes para mantê-lo longe da delinquência.

Pena final: reclusão de 02 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de reclusão de 02 anos e 04 meses, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, diária mínima.

O réu é reincidente específico, de forma que não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos.

O réu encontra-se em liberdade e assim poderá continuar, caso deseje recorrer desta sentença.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Tendo em vista que o(a)(s) réu(é)(s) manifestou(ram) desejo de recorrer da sentença, pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito: "recebo o recurso interposto pelo(a)(s) réu(é)(s), devendo a serventia providenciar a remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar as razões".

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):

Ré(u):